

- **Expediente N.º: EXP202317662**

RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO

Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 19 de junio de 2024, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a **MAXPOWER FITNESS NUTRITION, S.L.** (en adelante la parte reclamada). Notificado el acuerdo de inicio y tras analizar las alegaciones presentadas, con fecha 5 de noviembre de 2024 se emitió la propuesta de resolución que a continuación se transcribe:

<<

Procedimiento N.º: EXP202317662 (PS/00235/2024)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 26/09/23, **D.ª. A.A.A.** (la parte reclamante), interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

La reclamación se dirige contra la entidad, MAXPOWER FITNESS NUTRITION, S.L. con NIF.: B95763785, titular de la página web <https://nutrisano.es/> (la parte reclamada), por la presunta vulneración de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI).

En su escrito de reclamación manifiesta, entre otras cuestiones que, la web <https://nutrisano.es/> no cumple con los requisitos establecidos por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información, respecto a la "Política de Cookies".

SEGUNDO: Con fecha 26/12/23, de conformidad con lo estipulado en el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), por parte de esta Agencia, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante.

TERCERO: La Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos en cuestión, en virtud de los poderes de investigación otorgados a las autoridades de control en el artículo 58.1 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27/04/16, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que

respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos (RGPD), y de conformidad con lo establecido en el Título VII, Capítulo I, Sección segunda, de la LOPDGDD, teniendo conocimiento de las siguientes cuestiones:

a).- Con fechas 22/01/24 y 05/02/24 se envía mediante el sistema Notific@ requerimiento de información a la empresa reclamada. Ambas notificaciones resultan expiradas por incomparecencia.

b).- Con fecha 19/02/24 se reitera el envío por vía postal a la dirección de contacto registrada en la plataforma Axesor: *****DIRECCIÓN.1**, con resultado "Ausente en reparto".

c).- Con fecha 25/03/24 se reitera el envío a la dirección postal publicada en Google Maps de la tienda NUTRISANO en Bilbao: *****DIRECCIÓN.2**.

d).- Con fecha 25/03/24 se envían dos correos electrónicos a las direcciones de contacto anunciadas en su página de Facebook y en su página web: nutrisanotiendaonline@gmail.com y fullgasbilbao@gmail.com.

e).- Con fecha 11/04/24 tiene entrada escrito de respuesta al requerimiento realizado, en el cual, entre otras cuestiones, manifiesta lo siguiente:

- Sobre las medidas adoptadas en relación con los hechos expuestos en la reclamación afirman que tras la notificación por parte de la AEPD se han implementado las siguientes medidas: 1. *"Hemos contratado un nuevo servicio de Protección de Datos, con la abogada especializada en la materia y Delegada de Protección de Datos, **B.B.B.**"* 2. *Hemos instalado un nuevo sistema de plugin que ofrece de una manera más clara y accesible la posibilidad de gestionar las cookies.* 3. *Hemos actualizado y revisado los avisos legales disponibles en la web, y especialmente, la Política de Privacidad y la Política de Cookies, con indicación clara y completa de todas las cookies utilizada (nombre, tipo de cookie, finalidad, proveedor y, duración)* 4. *Hemos habilitado un nuevo canal de comunicación para recibir las reclamaciones en relación con la protección de datos, protecciondedatosnutrisano@gmail.com.*

- Sobre la información que ofrece el banner en relación con la política de privacidad exponen lo siguiente: *"El plugin instalado en la página web permite gestionar las cookies de una manera sencilla, fácil y accesible. Cuando una persona usuaria entra en la página web por primera vez, aparece un banner o plugin en el pie de página, en el cual se ofrece la opción de aceptar todas las cookies o rechazarlas todas. El consentimiento para ambas opciones es libre, sin que el rechazo de las cookies suponga limitación de algún tipo en la navegación web. Por lo tanto, las personas usuarias pueden rechazar libremente la instalación de cookies. Además, a través de ese plugin también se puede acceder directamente a la Política de Cookies, que está igualmente disponible en un enlace a pie de página, junto con el Aviso Legal y la Política de Privacidad. Los datos del responsable de tratamiento constan en la cabecera de dichos textos, incluyendo el email específico creado para recibir las reclamaciones relacionadas con la protección de los datos personales. En la Política de Cookies se informa de qué es una cookie y para qué sirve, sobre*

la aceptación de las cookies en este sitio web, qué tipos de cookies existen, cómo se pueden modificar las cookies según el navegador, y el listado de cookies concretas que utiliza el sitio web, indicando nombre, función, dominio, duración y finalidad.

Actualmente la web utiliza 10 cookies diferentes: De análisis: 3 (_fbpfb, _landing_page, _shopify_ye09a8099) De sesión: 2 (Session27, secure_customer_sign) De preferencias: 4 (popup-cookie, tracking_consent, localizationES, receive-cookie-deprecation1) Publicitarias: 1 (_cmp_a) De análisis: 3 (_fbpfb, _landing_page, _shopify_ye09a8099) La duración de esas cookies varía entre simplemente la sesión, 1 año o 2 años. No se utilizan cookies permanentes. Además, en la Política de Privacidad se informa de todos los datos personales que se tratan, así como de la finalidad del tratamiento, la base de legitimación, el origen de los datos, y cesiones y transferencias internacionales. También se informan de los derechos que ostentan las personas al facilitar los datos, y cómo puede ejercerlo, incluyendo el derecho a presentar una reclamación ante la AEPD y un enlace a los modelos de formularios disponibles en la agencia. Los datos personales que son tratados se limitan a los datos identificativos y de contacto, datos bancarios y de historial de compra, y datos recogidos a través de la navegación de forma automática.”

CUARTO: Con fecha 23/05/24 se obtienen y se diligencian las siguientes características de la “Política de Cookies” de la web <https://nutrisano.es/> :

a).- Sobre la utilización de cookies antes de que el usuario preste su consentimiento:

Al entrar en la web por primera vez, una vez limpiado el equipo terminal de historial de navegación y de cookies, sin aceptar nuevas cookies ni realizar ninguna acción sobre la página web, se ha comprobado, que se utilizan las siguientes cookies:

Cookies de naturaleza técnica o necesaria:

cookies	Dominio	Descripción
_cmp_a	.nutrisano.es	Se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento del usuario.
receiver-cookie-deprecation	.nutrisano.es	Se utiliza para indicar al propietario del sitio web la desactivación de las cookies que recibe el sistema.
keep_alive	.nutrisano.es	Se utiliza para mantener activa la sesión de un usuario en un sitio web.

cookies	Dominio	Descripción
Localización	nutrisano.es	Almacena las preferencias del usuario en cuanto a idioma y región.
secure_customer_sig	nutrisano.es	Relacionada con el inicio de sesión del cliente.

Cookies de Orientación o Publicidad comportamental: son aquellas que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo:

cookies	Dominio	Descripción
_tracking _consent	nutrisano.es	Shopify configura esta cookie para almacenar las preferencias de un usuario.

Cookies cuya función o ha podido ser identificada:

cookies	Dominio	Notas
Popup-cookie	nutrisano.es	

b).- Sobre el banner de información sobre cookies en la primera capa:

Al entrar en la web por primera vez, una vez limpiado el equipo terminal de historial de navegación y de cookies, sin realizar ninguna acción sobre la página web, aparece un banner de información sobre cookies con el siguiente mensaje:

<i>Valoramos su privacidad</i>		
<i>Utilizamos cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia, para fines de marketing y para recopilar análisis. Más información en la <<Política de Privacidad>>.</i>		
<<Administrar preferencias>>	<<Aceptar>>	<<Rechazar>>

Si se opta por rechazar todas las cookies (<<Rechazar>>), se observa como la web sigue utilizando las mismas cookies detectadas al inicio de la sesión.

Si se opta por gestionar las cookies de forma granular, (<<Administrar preferencias>>), se despliega un panel de control donde se observa que los grupos de cookies no se encuentran premarcados, pero si se desea no utilizar ninguna cookie que no sea de naturaleza técnica, cliqueando en la opción <<Rechazar todo>> sin haber seleccionado ninguno de los grupos de cookies de este panel de control, se observa como la web sigue utilizando las mismas cookies detectadas al inicio de la sesión.

c).- Sobre la posibilidad de modificar el consentimiento prestado sobre cookies, en cualquier momento de la navegación web.

Si el usuario hubiese prestado el consentimiento inicial para que la web utilice cookies que sean de naturaleza no técnica o necesarias cliqueando en la opción <<Aceptar>> existente en el banner inicial, o marcando los grupos de cookies que aparecen en el panel de control, se observa como la web empieza a utilizar nuevas cookies propias, aparte de las inicialmente detectadas al comienzo de la sesión.

Pero si se desea, durante la navegación web, modificar dicho consentimiento, NO existe la posibilidad de acceder nuevamente al panel de control de cookies para modificar el consentimiento, pues no existe ningún enlace permanente que posibilite esta opción.

No obstante, sobre esta cuestión, en la información proporcionada en la “Política de Cookies” de la web, <https://nutrisano.es/pages/data-sale-opt-out> se indica, respecto a la modificación del consentimiento, lo siguiente:

(...) 5.- ¿Cómo puedes modificar las cookies? Además, de seleccionar tu opción en el menú desplegable también puede personalizar el uso de cookies desde las opciones del navegador. Dependiendo del navegador, la configuración de las cookies estará en un lugar u otro. Podrá localizarla si usas la función “Ayuda” de su navegador. Puede también configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro. Entre los navegadores más comunes: (...)

d).- Sobre la información suministrada en la “Política de Cookies”:

Si se accede a la “Política de Cookies” a través del enlace existente en la parte inferior de la página principal, la web redirige al usuario a una nueva página <https://nutrisano.es/pages/data-sale-opt-out> donde se proporciona información sobre: qué son las cookies; para qué sirve la información recogida mediante las cookies; qué tipo de cookies existen y cuáles son las cookies que utiliza el sitio web y como gestionar las cookies a través del navegador instalado en el equipo terminal.

QUINTO: Con fecha 19/06/24, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la LPACAP, por la presunta vulneración del artículo 22.2 de la LSSI, tipificada como “leve” en el artículo 38.4 g), de la citada norma por las deficiencias detectadas en su política de cookies. Esto es, la utilización de cookies que no son de naturaleza técnica sin el previo consentimiento del usuario; la imposibilidad de prestar el consentimiento o rechazar la instalación de cookies que no

sean de naturaleza técnica o poderlo realizar de forma granular, y la imposibilidad de modificar el consentimiento en cualquier momento de la navegación web.

En el acuerdo de apertura se determinó que la sanción que pudiera corresponder, atendidas las evidencias existentes en ese momento y sin perjuicio de lo que resultase de la instrucción ascendería a un total de 2.000 (dos mil euros).

La notificación de la incoación del expediente se practicó conforme a las normas establecidas en la LPACAP. Según certificado del Servicio de Correos el escrito de incoación de expediente enviado mediante notificación electrónica, a la Delegada de Protección de Datos fue recogida el 28/06/24.

SEXTO: Con fecha 23/07/24, se recibe en esta Agencia escrito de alegaciones a la incoación del expediente donde se indica lo siguiente:

PRIMERA. Que, en virtud del Acuerdo de Inicio, la AEPD propone que se han cometido las siguientes infracciones: 1. Instalación de cookies sin consentimiento previo 2. Imposibilidad de rechazar o gestionar las cookies de forma granular 3. Falta de opción para modificar el consentimiento.

SEGUNDA. Que, tras la recepción inicial de la reclamación presentada a la AEPD, la empresa ha mostrado su voluntad de cumplir con todos los aspectos de la normativa, realizando los cambios que fueran necesarios para cumplir con la normativa, entre otros: - La contratación de un nuevo servicio de protección de datos - Implementación de un nuevo plugin para la gestión de cookies - Actualización de los avisos legales, Política de Privacidad, y Política de Cookies.

TERCERA. - Que, respecto a las cookies, la web utilizaba el plugin que la propia proveedora "Shopify" ofrecía a sus clientes, por defecto. No obstante, tras la notificación del Acuerdo se ha comprobado que el plugin no funcionaba siempre correctamente, mostrando algunos fallos de programación. Que realmente, se debe a un error externo de la entidad, de la que NUTRISANO no es responsable.

A partir de ello, se ha vuelto a realizar una revisión, y se ha contratado un nuevo plugin específico de pago, denominado "Pandectes GDPR Compliance", siempre bajo la premisa de voluntad de cumplir íntegramente lo exigido por la normativa.

CUARTA. Según lo investigado, se ha comprobado que, al entrar en la web por primera vez, se utilizan de forma directa las siguientes siete cookies: 1) _cmp_a ; 2) Receiver-cookie-deprecation; 3) keep_alive ; 4) Localización; 5) secure_customer_sig; 6) _tracking__consent, 7) Popup-cookie

Que respecto a las cinco primeras la AEPD confirma que son cookies técnicas y necesarias y, por ende, no existe ninguna infracción respecto a las mismas. No obstante, considera que hay otras dos cookies actividades por defecto que no son técnicas, calificación con la que no estamos de acuerdo:

A) Respecto a la cookie “_tracking__consent”: La resolución incoadora indica que es una cookie de orientación o publicidad comportamental, que “Shopify configura esta cookie para almacenar las preferencias de un usuario, brindar una experiencia de compra personalizada y sugerir artículos relacionados”. Sin embargo, eso no es cierto, como el propio nombre de la cookie anuncia, se trata de una cookie dirigida a almacenar preferencias del usuario relativas a privacidad, más concretamente, su elección en el plugin de la cookie. Por lo tanto, esta cookie es técnica y necesaria, dado que, sin ella, no sería posible guardar la selección del usuario respecto a la utilización de cookies.

En la Política de Cookies se explica de la siguiente manera: “Almacena las preferencias de consentimiento de rastreo del usuario.” Esta información puede comprobarse en la propia web que informa de las cookies disponibles en Shopify: <https://www.shopify.com/legal/cookies>

B) Respecto a la cookie “Popup-cookie”: Indica la AEPD que no ha podido identificar la finalidad de la cookie. Como su propio nombre indica, sirve para garantizar que el plugin de cookies se ha activado, es decir, que ha aparecido al usuario cuando entre en la web. En la política de privacidad se indica la finalidad: “Indica si el usuario ha visto el aviso de cookies.”

El acuerdo de iniciación alega, que tras seleccionar la opción <<Rechazar todo>>

“se observa como la web sigue utilizando las mismas cookies detectadas al inicio

de la sesión”, y esto se debe, a que las cookies utilizas en el inicio de sesión son

únicamente las cookies técnicas o necesarias. Es decir, si se rechazan las cookies, se seguirán utilizando las cookies técnicas, porque son necesarias, si bien, no se activarán el resto de las cookies de preferencia o publicidad, que solo funcionarán en caso de aceptarse expresamente tipo de cookies.

Es en ese supuesto, cuando se clicla la opción <<Aceptar>> se observa como la web empieza a utilizar nuevas cookies propias, aparte de las inicialmente detectadas al comienzo de la sesión, que corresponden a las cookies optativas.

En consecuencia, únicamente se utilizan cookies con finalidad técnica y necesaria cuando el usuario entra en la página web, y no ha otorgado su consentimiento expreso para otro tipo de cookies, de acuerdo, con lo establecido en el art.22.2 LSSI y en el Dictamen 4/2012 del GT29.

QUINTA. Que ciertamente, el anterior plugin instalado no permitía gestionar las cookies de forma granular. No obstante, el nuevo plugin sí que permite las siguientes tres opciones. En el mismo lugar que aparece el plugin o pop-up de cookies por primera vez, se mantiene el logo de una galleta (“cookie”), que los usuarios pueden clicar para volver a entrar en el menú de cookies. En dicho menú, encontrarán las siguientes opciones: - “Aceptar todo”: mediante este botón grande, se permite al usuario aceptar todo tipo de cookies de manera

sencilla y directa. - “Rechazar todo”: mediante este botón grande, se permite al usuario rechazar las cookies con un solo paso. - “Preferencias”: clicando en esta opción, se abre un panel que permite al usuario, aceptar o rechazar cookies de manera granular. Todas las opciones están premarcadas.

SÉXTA - Reconocemos el error, y consideramos que ha sido un incidente de naturaleza técnica (no permitir la selección de manera granular, y no permitir modificar con posterioridad el consentimiento). Se trata, por tanto, de un error concreto e involuntario debido a un fallo aislado.

Que el propio plugin por defecto de Shopify aseguraba cumplir la normativa, sin embargo, posteriormente, generaba varios fallos de programación que impedían que se cumpliera íntegramente.

Respecto a las cookies realmente utilizadas, consideramos que no ha existido ninguna vulneración de la privacidad o los datos personales, dado que únicamente se han utilizado cookies técnicas y necesarias sin el consentimiento expreso del usuario.

SÉPTIMA. Se han adoptado todas las medidas necesarias correctivas inmediatas y preventivas para solucionar el problema tan pronto como se ha tenido conocimiento de éste.

Insistimos que la voluntad es cumplir en todo momento con la normativa, y respetar siempre los derechos y libertades de todas las personas usuarias. Por lo tanto, no ha existido mala fe, y existe un verdadero compromiso con el cumplimiento normativo.

OCTAVA. En consecuencia, solicitamos que la AEPD aplique la doctrina que establece de manera habitual en muchas otras resoluciones, en virtud de la Sentencia de 1 de diciembre de 2006 de la Audiencia Nacional (entre otras: E/07296/2020; E/04518/2021; E/08765/2020), por la cual: “Se ha de hacer hincapié en que esa simple inobservancia no puede ser entendida que en el derecho administrativo sancionador rija la responsabilidad objetiva. Efectivamente, en materia sancionadora rige el principio de culpabilidad (SSTC 15/1999, de 4 de julio; 76/1990, de 26 de abril; y 246/1991, de 19 de diciembre), lo que significa que ha de concurrir alguna clase de dolo o culpa. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1998, “... puede hablarse de una decidida línea jurisprudencial que rechaza en el ámbito sancionador de la Administración la responsabilidad objetiva, exigiéndose la concurrencia de dolo o culpa, en línea con la interpretación de la STC 76/1990, de 26 de abril, al señalar que el principio de culpabilidad puede inferirse de los principios de legalidad y prohibición de exceso (artículo 25 de la Constitución) o de las exigencias inherentes al Estado de Derecho”. Por lo expuesto,

SOLICITO a la Agencia Española de Protección de Datos que tenga por presentadas estas alegaciones, y tras admitirlas, en virtud del principio de culpabilidad y la demostrada buena fe y voluntad de cumplimiento normativo por parte de MAXPOWER FITNESS NUTRITION, S.L., archive el presente procedimiento sancionador o, subsidiariamente, reduzca la sanción propuesta

al mínimo posible, considerando la naturaleza técnica y aislada del incidente y las medidas correctivas y preventivas adoptadas.

SÉPTIMO: Con fecha 17/09/24 se obtienen y se diligencian las siguientes características de la “Política de Cookies” de la web <https://nutrisano.es/>:

a).- Sobre la utilización de cookies antes de que el usuario preste su consentimiento:

Al entrar en la web por primera vez, una vez limpiado el equipo terminal de historial de navegación y de cookies, sin aceptar nuevas cookies ni realizar ninguna acción sobre la página web, se ha comprobado, que se utilizan las siguientes cookies:

Cookies de naturaleza técnica o necesaria:

cookies	Dominio	Descripción
_cmp_a	.nutrisano.es	Se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento del usuario.
receiver-cookie-deprecation	.nutrisano.es	Se utiliza para indicar al propietario del sitio web la desactivación de las cookies que recibe el sistema.
keep_alive	.nutrisano.es	Se utiliza para mantener activa la sesión de un usuario en un sitio web.
Localización	nutrisano.es	Almacena las preferencias del usuario en cuanto a idioma y región.
secure_customer_sig	nutrisano.es	Relacionada con el inicio de sesión del cliente.

Cookies de Orientación o Publicidad comportamental:

cookies	Dominio	Descripción
_tracking_consent	nutrisano.es	Shopify configura esta cookie para almacenar las preferencias de un usuario.

Cookies cuya función o ha podido ser identificada:

cookies	Dominio	Notas aclaratorias
Popup-cookie	nutrisano.es	<i>Parece, por su nombre, estar relacionada con la gestión de ventanas emergentes o "pop-ups" en el sitio web. Este tipo de cookie suele emplearse para recordar si un usuario ya ha visto o interactuado con un pop-up en particular, con el fin de evitar mostrarlo repetidamente durante la misma sesión o en visitas futuras.</i>

b).- Sobre el banner de información sobre cookies en la primera capa:

Al entrar en la web por primera vez, una vez limpiado el equipo terminal de historial de navegación y de cookies, sin realizar ninguna acción sobre la página web, aparece un banner de información sobre cookies en la parte inferior de la página principal con el siguiente mensaje:

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia. <<Ver Política de Cookies>>.

<<Preferencias>> <<Aceptar>> <<Rechazar>>

Si se opta por rechazar las cookies (<<Rechazar>>) se comprueba como la web, además de seguir utilizando las cookies detectadas al inicio de la sesión, empieza a utilizar una nueva cookie:

cookies	Dominio	Descripción
receive-cookie-deprecation	nutrisano.es	Su misión es la de registrar y gestionar el rechazo del consentimiento para la instalación de cookies no esenciales.

Si se opta por gestionar las cookies de forma granular, cliqueando en la opción <<preferencias>>, se despliega un panel de control donde se observa que los grupos de cookies están premarcados en la posición "OFF" (desactivados):

Si se desea no prestar el consentimiento a la utilización de cookies que no sean de naturaleza técnica, cliqueando en la opción <<Rechazar todo>> sin haber seleccionado ninguno de los grupos de cookies, se comprueba como la web sigue utilizando las mismas cookies detectadas al principio.

Si se desea prestar el consentimiento a la utilización de cookies que no sean de naturaleza técnica, cliqueando la opción <<aceptar>> situado en el banner de información inicial o en el panel de control, desplazando los cursores de los grupos de

cookies de la posición “OFF” a la posición “ON” y cliqueando <<guardar preferencias>> se observa como la web empieza a utilizar cookies, tanto propias como de terceros (cuyo proveedor es “Shopify” aunque aparezcan en la web bajo el dominio de “nutrisano.es”):

cookies	Dominio	Descripción
_pandectes _gdpr	.nutrisano.es	Tiene la misión de gestionar el estado del consentimiento del usuario con respecto al uso de cookies en el sitio web, en cumplimiento de la normativa GDPR. Esta cookie es técnica y no necesita consentimiento, ya que su finalidad es recordar y aplicar las elecciones del usuario sobre el uso de otras cookies que sí requieren consentimiento.
_shopify_s	.nutrisano.es	Tiene una misión doble: gestionar la sesión del usuario en la tienda en línea, asegurando que el sitio web funcione correctamente durante la navegación (función técnica) y recopilar datos de análisis sobre el comportamiento del usuario para optimizar la tienda en línea y mejorar la experiencia del cliente (función de análisis). Dado que también se utiliza para fines de análisis y seguimiento, requiere el consentimiento del usuario para ser instalada.
_shopify_sa_p	.nutrisano.es	Tiene como misión realizar el seguimiento del comportamiento del usuario con respecto a campañas publicitarias y contenido social, así como recolectar datos analíticos de marketing. Esta cookie requiere el consentimiento del usuario, ya que su uso se enfoca en el seguimiento y análisis del comportamiento para optimizar las estrategias publicitarias y de marketing de las tiendas en línea.
_shopify_sa_t	nutrisano.es	Tiene como misión realizar el seguimiento del comportamiento del

cookies	Dominio	Descripción
		usuario con respecto a campañas publicitarias y estrategias de retargeting. También puede recolectar datos sobre la interacción del usuario con contenido social. Esta cookie requiere el consentimiento del usuario antes de ser instalada, ya que se utiliza principalmente para realizar seguimiento y análisis publicitario, lo que la clasifica como una cookie de marketing y seguimiento.

c).- Sobre la posibilidad de modificar el consentimiento prestado sobre cookies, en cualquier momento de la navegación web.

Si el usuario ha prestado el consentimiento inicial para que la web utilice cookies que sean de naturaleza técnica o necesarias y desea, en un momento determinado de la navegación web, modificar dicho consentimiento, existe la posibilidad de acceder nuevamente al panel de control a través del enlace (un logo de galleta), existente en la parte inferior izquierda:

Si se cliquea en el “logo” aparece de nuevo el banner de información de cookies, a través del cual se puede acceder al panel de control, cliqueando en la opción de <<preferencias>>:

Si ahora se cliquea en la opción <<rechazar todas>> se observa como la web sigue utilizando las mismas cookies detectadas cuando se prestó el consentimiento. Esto es, la web no deshabilita las cookies, siguen presentes en el terminal:

d).- Sobre la información suministrada en la “Política de Cookies”:

Si se accede a la “Política de Cookies” a través del enlace existente en la parte inferior de la página principal, la web redirige al usuario a una nueva página <https://nutrisano.es/pages/data-sale-opt-out> con la siguiente información:

“Como se describe en nuestra Política de privacidad, recopilamos información personal de sus interacciones con nosotros y nuestro sitio web, incluso a través de cookies y tecnologías similares. También podemos compartir esta información personal con terceros, incluidos socios publicitarios. Hacemos esto para mostrarle anuncios en otros sitios web que sean más relevantes para sus intereses y por otros motivos que se describen en nuestra Política de privacidad.

Compartir información personal para realizar publicidad dirigida en función de su interacción en diferentes sitios web puede considerarse “venta”, “intercambio” o “publicidad dirigida” según determinadas leyes de privacidad de

los estados de EE. UU. En función de dónde viva, puede tener derecho a darse de baja de estas actividades. Si desea ejercer este derecho a la baja voluntaria, siga las instrucciones a continuación.

Si visita nuestro sitio web con la señal de preferencia de darse de baja del Control Global de Privacidad activada, trataremos esto, según su ubicación, como una solicitud para darse de baja de la actividad que pueda considerarse una “venta” o “intercambio” de información personal. También lo trataremos como una solicitud de baja de otros usos que puedan considerarse publicidad dirigida para el dispositivo y navegador que utilizó al visitar nuestro sitio web.

Si desea darse de baja de actividades que puedan considerarse “venta” o “intercambio”, o “publicidad dirigida”, envíe un correo electrónico.

A la vista de todo lo actuado, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en el presente procedimiento se consideran hechos probados los siguientes,

HECHOS PROBADOS

Primero: Según consta en la página web <https://nutrisano.es/> el responsable de la misma es la entidad MAXPOWER FITNESS NUTRITION, S.L. con NIF.: B95763785,

Segundo: Queda constancia en el expediente de las características de la “Política de Cookies” de la web <https://nutrisano.es/> obtenidas y diligenciadas el 23/05/24:

a).- Sobre la utilización de cookies antes de que el usuario preste su consentimiento:

- Cookies de naturaleza técnica: “_cmp_a” ; “receiver-cookie-deprecation” ; “keep_alive” ; “Localización” y “secure_customer_”
- Cookies de Orientación o Publicidad comportamental: “_tracking_consent”
- Cookies cuya función o ha podido ser identificada: “Popup-cookie”

b).- Sobre la prestación del consentimiento para la utilización de cookies que no sean de naturaleza técnica:

- Si se opta por rechazar todas las cookies (<<Rechazar>>) en el banner inicial, se observa como la web sigue utilizando las mismas cookies detectadas al inicio de la sesión.
- Si se opta por gestionar las cookies de forma granular, (<<Administrar preferencias>>), en el banner inicial, se despliega un panel de control donde se observa que los grupos de cookies no se encuentran premarcados, pero si se desea no utilizar ninguna cookie que no sea de naturaleza técnica, cliqueando en la opción <<Rechazar todo>> sin haber seleccionado ninguno de los grupos de cookies de este panel de control, se observa como la web sigue utilizando las mismas cookies detectadas al inicio de la sesión.

c).- Sobre la posibilidad de modificar el consentimiento prestado sobre cookies, en cualquier momento de la navegación web.

- Si el usuario hubiese prestado el consentimiento inicial para que la web utilice cookies que sean de naturaleza no técnica o necesarias y desea, durante la navegación web, modificar dicho consentimiento, NO existe la posibilidad de acceder nuevamente al panel de control de cookies para modificar el consentimiento, pues no existe ningún enlace permanente que lo posibilite.

d).- Sobre la información suministrada en la “Política de Cookies”:

- Si se accede a la “Política de Cookies” se proporciona información sobre: qué son las cookies; para qué sirve la información recogida mediante las cookies; qué tipo de cookies existen y cuáles son las cookies que utiliza el sitio web y como gestionarlas a través del navegador instalado en el equipo terminal.

Tercero: Queda constancia en el expediente de las características de la “Política de Cookies” de la web <https://nutrisano.es/> obtenidas y diligenciadas el 17/09/24:

a).- Sobre la instalación de cookies en el equipo terminal previo al consentimiento:

- Cookies de naturaleza técnica: “_cmp_a” ; “receiver-cookie-deprecation” ; “keep_alive” ; “Localización” y “secure_customer_”
- Cookies de Orientación o Publicidad comportamental: “_tracking_consent”
- Cookies cuya función o ha podido ser identificada: “Popup-cookie”

b).- Sobre la prestación del consentimiento para la utilización de cookies que no sean de naturaleza técnica:

- Si se opta por rechazar las cookies (<<Rechazar>>) en el banner inicial se comprueba como la web sigue utilizando las cookies detectadas al principio.
- Si se opta por gestionar las cookies de forma granular, cliqueando en la opción <<preferencias>>, se despliega un panel de control donde se observa que los grupos de cookies están premarcados en la posición “OFF” (desactivados): Si se desea no prestar el consentimiento a la utilización de cookies que no sean de naturaleza técnica, cliqueando en la opción <<Rechazar todo>> sin haber seleccionado ninguno de los grupos de cookies, se comprueba como la web sigue utilizando las mismas cookies detectadas al principio.
- Si se desea prestar el consentimiento a la utilización de cookies que no sean de naturaleza técnica, cliqueando la opción <<aceptar>> situado en el banner de información inicial o en el panel de control, desplazando los cursores de los grupos de cookies de la posición “OFF” a la posición “ON” y cliqueando <<guardar preferencias>> se observa como la web empieza a utilizar cookies, tanto propias como de terceros (cuyo proveedor es “Shopify” aunque aparezcan en la web bajo el dominio de “nutrisano.es”:

c).- Sobre la posibilidad de modificar el consentimiento prestado sobre cookies, en cualquier momento de la navegación web.

- Si el usuario ha prestado el consentimiento inicial para que la web utilice cookies que sean de naturaleza técnica o necesarias y desea, en un momento

determinado de la navegación web, modificar dicho consentimiento, existe la posibilidad de acceder nuevamente al panel de control a través del enlace (un logo de galleta), existente en la parte inferior izquierda.

- Si se cliquea en el “logo” aparece de nuevo el banner de información de cookies, a través del cual se puede acceder al panel de control, cliqueando en la opción de <<preferencias>>.
- Si ahora se cliquea en la opción <<rechazar todas>> se observa como la web sigue utilizando las mismas cookies detectadas cuando se prestó el consentimiento. Esto es, la web no deshabilita las cookies que no son técnicas o necesarias, siguen presentes en el terminal.

d) Información suministrada en la “Política de Cookies”:

- Se ha comprobado que en la “Política de Cookies” no incluye información sobre: la definición y función genérica de las cookies; sobre el tipo de cookies que se utilizan y su finalidad; sobre la forma de aceptar, denegar o revocar el consentimiento para el uso de cookies; no identifica quién utiliza las cookies, esto es, si la información obtenida por las cookies es tratada solo por el editor y/o también por terceros; sobre la forma de aceptar, denegar o revocar el consentimiento para el uso de cookies y sobre el periodo de conservación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1 de la LSSI y lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la LOPDGDD, es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: *"Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se registrarán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos."*

La Disposición adicional cuarta "Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes" establece que: *"Lo dispuesto en el Título VIII y en sus normas de desarrollo será de aplicación a los procedimientos que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera de tramitar en ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes."*

II

Contestación a las alegaciones presentadas.

Primero: En el apartado “cuarto” de su escrito de alegaciones, la entidad reclamada defiende que la cookie “_tracking__consent”, está clasificada incorrectamente como una cookie de orientación o publicidad comportamental pues, según afirman, esta cookie

tiene una finalidad técnica ya que almacena las preferencias del usuario en cuanto a privacidad, particularmente su elección en el plugin de consentimiento de cookies, lo cual la exceptúa. Además, indica que esta información se apoya en la Política de Cookies de “Shopify” y en fuentes públicas verificables.

Pues bien, empecemos indicando que el nombre de la cookie “_tracking_consent” puede ser bastante descriptivo pues sugiere que está relacionada con la gestión o el almacenamiento del consentimiento para el seguimiento del usuario en la página web. Este tipo de cookie generalmente se emplea para registrar si un usuario ha otorgado o no su consentimiento para el uso de cookies de seguimiento, que pueden incluir cookies publicitarias o de análisis de datos.

Si la cookie se usa solo para almacenar el consentimiento, no requiere consentimiento directo, ya que no es una cookie que rastrea ni almacena información personal por sí misma. Sin embargo, si está relacionada con otros procesos de seguimiento o análisis de comportamientos del usuario, entonces sí requeriría consentimiento.

Si observamos el valor de la cookie antes de que el usuario preste el consentimiento es:

```
{"con":{"CMP":{"a":"","m":"","p":"","s":""}}, "v":"2.1", "region":"ES", "reg":"GDPR"}
```

"con" (Consentimiento): Este campo se refiere al "consentimiento" del usuario. Dentro de este objeto, parece haber una subestructura llamada "CMP".

"CMP" (Consent Management Platform): CMP es un acrónimo utilizado para referirse a las Plataformas de Gestión de Consentimiento, que son servicios que gestionan el consentimiento del usuario conforme a la legislación de privacidad, como el GDPR. Dentro de este objeto CMP, encontramos varias subclaves:

"a" (advertising): relacionado con el consentimiento para recibir anuncios o para el seguimiento con fines publicitarios.

"m" (marketing): está vinculado al consentimiento para actividades de marketing.

"p" (personalización): se refiere a la personalización de contenido o publicidad en función de los datos del usuario.

"s" (seguimiento o estadísticas): Está relacionado con el seguimiento de estadísticas o análisis de datos.

Todos estos campos están vacíos (""), lo que indica que aún no se ha establecido un valor, o que el usuario no ha dado su consentimiento explícito para ninguna de estas categorías.

"v" (versión): "2.1" indica la versión de la estructura de consentimiento.

"region": "ES": Este campo indica la región en la que se encuentra el usuario.

"reg": "GDPR": El campo "reg" hace referencia a la legislación de privacidad bajo la cual se está gestionando el consentimiento del usuario, que en este caso es el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos).

La interpretación general del valor de la cookie es que tiene un estado de consentimiento vacío por defecto, en el cual aún no se ha dado o registrado el consentimiento del usuario para ninguna de las categorías de cookies que pudieran estar relacionadas con publicidad, marketing, personalización o seguimiento. El valor está registrado bajo la normativa del RGPD en la región específica de España.

Ahora, si el usuario no ha prestado el consentimiento a la utilización de cookies que no sean técnicas o necesarias rechazando la utilización de las mismas en el banner inicial se observa que la cookie en cuestión tiene ahora el siguiente valor:

```
{"con":{"CMP":  
{"a":"0","m":"0","p":"0","s":""}}, "v":"2.1","region":"ESCL","reg":"GDPR"}
```

"con" (Consentimiento): Este sigue siendo el objeto que contiene las decisiones del usuario respecto al consentimiento. Dentro de "CMP" (Consent Management Platform), ahora vemos algunos valores actualizados:

*"a": "0" (advertising)**: El valor "0" aquí significa que el usuario ha rechazado el consentimiento para cookies relacionadas con la publicidad.*

*"m": "0" (marketing)**: Similarmente, el valor "0" indica que el usuario ha rechazado las cookies relacionadas con actividades de marketing.*

*"p": "0" (personalización)**: El valor "0" en este campo indica que el usuario ha rechazado el consentimiento para cookies que permiten la personalización de contenido o publicidad.*

"s": "" (estadísticas o seguimiento): Este campo sigue vacío, lo que puede indicar que no se ha registrado una decisión para este tipo de cookies, o bien que no están activas en este caso específico.

En resumen, el usuario ha rechazado explícitamente las cookies relacionadas con la publicidad, marketing y personalización.

"v" (versión): El valor "v": "2.1" permanece igual.

"region": "ESCL": Aquí vemos un cambio interesante. El valor "ESCL" probablemente hace referencia a España (ES) y las Islas Canarias (CL).

"reg": "GDPR": Este campo sigue indicando que la normativa que se aplica es el GDPR, lo cual es consistente con la normativa de protección de datos de la UE

Por tanto, del análisis de la cookie se desprende que, los valores de "0" en los campos de "a", "m" y "p" confirman que el usuario ha rechazado el consentimiento para la

instalación de cookies relacionadas con la publicidad, marketing y personalización. El campo "s" está vacío, lo que puede indicar que no se ha solicitado consentimiento para el seguimiento/estadísticas o que no se ha registrado una respuesta.

En relación con la cookie "Popup-cookie":

La reclamada alega que su finalidad es técnica, ya que garantiza que el aviso de cookies se ha mostrado al usuario al ingresar a la web. La AEPD no identificó su propósito, pero en la Política de Privacidad se especifica que indica si el usuario ha visto dicho aviso. Además, se argumenta que, tras rechazar todas las cookies, solo permanecen activas las cookies técnicas o necesarias, cumpliendo con la LSSI y el Dictamen 4/2012 del GT29, sin activar cookies de preferencia o publicidad sin consentimiento.

Pues bien, la cookie "popup-cookie" parece, por su nombre, estar relacionada con la gestión de ventanas emergentes o "pop-ups" en el sitio web. Este tipo de cookie suele emplearse para recordar si un usuario ya ha visto o interactuado con un pop-up o ventana emergente en particular, con el fin de evitar mostrarlo repetidamente durante la misma sesión o en visitas futuras.

Si la cookie "popup-cookie" se utiliza únicamente para gestionar el comportamiento del pop-up y mejorar la experiencia del usuario (por ejemplo, evitar mostrar la misma ventana emergente repetidamente en la misma sesión o en visitas sucesivas), podría considerarse una cookie técnica pues no rastrea al usuario más allá de lo estrictamente necesario para ofrecer la funcionalidad básica del sitio, como recordar si ya ha cerrado un pop-up y no volverle a abrir.

Sin embargo, si la cookie "popup-cookie" tiene una función más allá de la gestión del pop-up en sí y se utiliza para realizar algún tipo de seguimiento o para mostrar contenido personalizado en futuras visitas (como anuncios personalizados dentro del pop-up que se ha abierto), entonces sí requeriría el consentimiento del usuario. Esto aplicaría si se usa para analizar cómo los usuarios interactúan con los pop-ups de una manera que implique el seguimiento de comportamiento o preferencias a lo largo del tiempo.

Si observamos el valor de la cookie antes de que el usuario preste el consentimiento para la utilización o no de cookies que no sean técnicas o necesarias, su valor es "true", que puede estar indicando que el pop-up ya ha sido mostrado al usuario, lo que evita que vuelva a aparecer durante la misma sesión o en visitas futuras. Es una forma de marcar que el usuario ha interactuado con el pop-up (ventana emergente).

Por tanto, si la cookie "popup-cookie" simplemente guarda el estado de si el pop-up ya ha sido mostrado o cerrado, esto se puede considerar un comportamiento técnico, necesario para mejorar la experiencia del usuario. Como tal, no requeriría consentimiento explícito, ya que su propósito es funcional y no implica rastreo del usuario para fines publicitarios o analíticos.

Pues bien, una vez comprobado que las cookies "_tracking_consent" y "popup-cookie" objeto de la controversia en este expediente sancionador, pueden tener una finalidad estrictamente técnica y por tanto no necesitan el consentimiento o también

pueden actuar como cookies que necesitan el consentimiento, lo ideal sería verificar la política de cookies de la página para obtener más detalles sobre el uso específico de estas cookies en dicho sitio web. Sin embargo, en el presente caso, cuando se ha accedido a la "Política de Cookies" de la página web www.nutrisano.es (<https://nutrisano.es/pages/data-sale-opt-out>) se ha observado que no existe ningún tipo de información sobre las mismas. Solamente existe la siguiente información:

"No vender ni compartir mi información personal.

Como se describe en nuestra Política de privacidad, recopilamos información personal de sus interacciones con nosotros y nuestro sitio web, incluso a través de cookies y tecnologías similares. También podemos compartir esta información personal con terceros, incluidos socios publicitarios. Hacemos esto para mostrarle anuncios en otros sitios web que sean más relevantes para sus intereses y por otros motivos que se describen en nuestra Política de privacidad.

Compartir información personal para realizar publicidad dirigida en función de su interacción en diferentes sitios web puede considerarse "venta", "intercambio" o "publicidad dirigida" según determinadas leyes de privacidad de los estados de EE. UU. En función de dónde viva, puede tener derecho a darse de baja de estas actividades. Si desea ejercer este derecho a la baja voluntaria, siga las instrucciones a continuación.

Si visita nuestro sitio web con la señal de preferencia de darse de baja del Control Global de Privacidad activada, trataremos esto, según su ubicación, como una solicitud para darse de baja de la actividad que pueda considerarse una "venta" o "intercambio" de información personal. También lo trataremos como una solicitud de baja de otros usos que puedan considerarse publicidad dirigida para el dispositivo y navegador que utilizó al visitar nuestro sitio web.

Si desea darse de baja de actividades que puedan considerarse "venta" o "intercambio", o "publicidad dirigida", envíe un correo electrónico".

Por tanto, en relación con las cookies denominadas "_tracking_consent" y "popup-cookie", y tras el análisis llevado a cabo expuesto anteriormente, se podrían considerar de carácter estrictamente técnico, en cuyo caso no precisarían del consentimiento del usuario para su implementación. No obstante, debido a que también pueden ser utilizadas para finalidades distintas a las estrictamente técnicas, es posible que en determinados casos sí requieran dicho consentimiento. Por esta razón, y con el fin de asegurar la transparencia y la correcta adecuación de su uso a la normativa vigente, se debe certificar de manera específica la finalidad para la que se emplean las cookies.

No obstante, en la revisión realizada el 17/09/24 sobre la "Política de Cookies" en el sitio web <https://nutrisano.es/pages/data-sale-opt-out>, no se ha encontrado ningún tipo de información que certifique los fines de las cookies que utiliza la web lo que permitiría conllevar la presunción de que dichas cookies cumplen exclusivamente una función técnica, tal y como alega la reclamada, no requiriendo en consecuencia el consentimiento explícito del usuario para su uso.

Segundo: En el punto “quinto” de su escrito de alegaciones, la reclamada reconoce que el anterior plugin instalado no permitía gestionar las cookies de forma granular pero que ya está modificado y el nuevo plugin permite una gestión granular de las cookies, ofreciendo tres opciones: “Aceptar todo”, “Rechazar todo” y “Preferencias”.

Pues bien, en la comprobación realizada por esta Agencia el pasado 17/09/24 se observó que si se opta por gestionar las cookies de forma granular, cliqueando en la opción <<preferencias>> en el banner de información sobre cookies de la página principal, se despliega un panel de control donde se observa que los grupos de cookies están premarcados en la posición “OFF” (desactivados). Si se desea no prestar el consentimiento a la utilización de cookies que no sean de naturaleza técnica, cliqueando en la opción <<Rechazar Todo>> sin haber seleccionado ninguno de los grupos de cookies, se comprueba como la web sigue utilizando las mismas cookies detectadas al principio y si se desea prestar el consentimiento a la utilización de cookies que no sean de naturaleza técnica, cliqueando la opción <<Aceptar>> o desplazando los cursores de los grupos de cookies de la posición “OFF” a la posición “ON” y cliqueando <<Guardar Preferencias>> se observa como la web empieza a utilizar nuevas cookies, (cuyo proveedor es “Shopify” aunque aparezcan en la web bajo el dominio de “nutrisano.es”): “_pandectes”; “_gdpr”; “_shopify_s”; “_shopify_sa_p” y “_shopify_sa_t”.

Sigue indicando la reclamada en este punto que ahora los usuarios pueden volver al panel de control clicando en el ícono permanente de una galleta situada en la parte inferior izquierda de la página web para ajustar sus preferencias de manera sencilla y directa en cualquier momento de la navegación web.

No obstante, se ha comprobado que si el usuario ha prestado el consentimiento inicial para que la web utilice cookies que sean de naturaleza técnica o necesarias y desea, en un momento determinado de la navegación web, modificar dicho consentimiento, aunque existe la posibilidad de acceder nuevamente al panel de control a través del enlace “logo de galleta”, si ahora se cliquea en la opción <<Rechazar Todas>> se observa como la web sigue utilizando las mismas cookies detectadas cuando se prestó el consentimiento. Esto es, la web no deshabilita las cookies que no son técnicas o necesarias, pues siguen presentes en el equipo terminal.

Tercero: Manifiesta la reclamada en el punto “séptimo” de su escrito de alegaciones que se han adoptado todas las medidas necesarias correctivas y preventivas para solucionar los problemas y que no ha existido nunca mala fe pues existe un verdadero compromiso con el cumplimiento normativo.

Pues bien, en la visita realizada y diligenciada por esta Agencia a la página web www.nutrisano.es el pasado día 17/09/24 se detectaron nuevas deficiencias en la “Política de Cookies” de la web. A saber:

a).- Sobre la instalación de cookies en el equipo terminal previo al consentimiento, en especial sobre las cookies “_tracking_consent” y “Popup-cookie” aunque, como se ha visto, pueden tener una finalidad técnica no existe ningún tipo de información sobre las mismas en la “Política de Cookies” de la web que certifique su carácter técnico.

b).- Sobre el banner de información de cookies existente en la primera capa (página principal), conteniendo la siguiente información “Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia” , no identifica las finalidades de las cookies que se utilizarán; no informa sobre si las cookies que se van a utilizar son propias (del responsable de la página web) o también de terceros asociados a él y no informa genéricamente sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso de que se elaboren perfiles de los usuarios.

c).- Sobre la posibilidad de modificar el consentimiento prestado sobre cookies, en cualquier momento de la navegación web, se ha detectado que si el usuario ha prestado el consentimiento inicial para que la web utilice cookies que sean de naturaleza técnica o necesarias y desea, en un momento determinado de la navegación web, modificar dicho consentimiento, existe ahora la posibilidad de acceder nuevamente al panel de control. No obstante, si ahora se desea retirar el consentimiento prestado a la utilización de cookies que no sean técnicas o necesarias las cookies instaladas siguen presentes.

d) Información suministrada en la “Política de Cookies” de la web, expuesta anteriormente no se incluye información sobre: definición y función genérica de las cookies; información sobre el tipo de cookies que se utilizan y su finalidad; información sobre la forma de aceptar, denegar o revocar el consentimiento para el uso de cookies; identificación de quién utiliza las cookies, esto es, si la información obtenida por las cookies es tratada solo por el editor y/o también por terceros; información sobre la forma de aceptar, denegar o revocar el consentimiento para el uso de cookies; en su caso, información sobre las transferencias de datos a terceros países realizadas por el editor y periodo de conservación de los datos.

III

Tipificación de la posible infracción cometida

Por tanto, de las deficiencias que siguen presentes respecto de la política de cookies en la página web <https://nutrisano.es/>, con respecto a la incoación del expediente pueden suponer la vulneración del artículo 22.2 de la LSSI, pues establece lo siguiente:

“Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personal.

Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones.

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente

necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario”.

IV.

Graduación de la Sanción

Esta infracción está tipificada como “leve” en el artículo 38.4 g), de la citada Ley, que considera como tal: *“Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos cuando no se hubiera facilitado la información u obtenido el consentimiento del destinatario del servicio en los términos exigidos por el artículo 22.2.”*, pudiendo ser sancionada con multa de hasta 30.000 €, de acuerdo con el artículo 39 de la citada LSSI.

La LSSI, en su artículo 40, establece la “graduación de la cuantía de las sanciones”, atendiendo a los siguientes criterios: a) *La existencia de intencionalidad.* b) *Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.* c) *La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.* d) *La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.* e) *Los beneficios obtenidos por la infracción.* f) *Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.* g) *La adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria aplicable respecto a la infracción cometida, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 18 o en la disposición final octava y que haya sido informado favorablemente por el órgano u órganos competentes.*

Tras las evidencias obtenidas se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con los siguientes criterios agravantes, que establece el art. 40 de la LSSI:

- La existencia de intencionalidad (apartado a). Expresión que ha de interpretarse como equivalente a grado de culpabilidad de acuerdo con la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12/11/07 recaída en el Recurso núm. 351/2006, al ser responsabilidad de la entidad reclamada la inexistencia de un sistema adecuado a la LSSI en su página web.

A la vista de lo expuesto se procede a emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero: Que por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos se sancione a la entidad, MAXPOWER FITNESS NUTRITION, S.L. con NIF.: B95763785, titular de la página web <https://nutrisano.es/> por la infracción del artículo 22.2 de la LSSI, tipificada como “leve” en el artículo 38.4 g), de la misma norma con una sanción de 2.000 euros (dos mil euros).

Segundo: Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 85.2 de la LPACAP, se le informa de que podrá, en cualquier momento anterior a la resolución del presente procedimiento, llevar a cabo el pago voluntario de la sanción propuesta, lo que supondrá una reducción de un 20% del importe de esta.

Con la aplicación de esta reducción, la sanción quedaría establecida en 1.600 euros (mil seiscientos euros) y su pago implicará la terminación del procedimiento. La

efectividad de esta reducción estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

En caso de que optara por proceder al pago voluntario de la cantidad especificada anteriormente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85.2 citado, deberá hacerla efectiva mediante su ingreso en la cuenta restringida **Nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000** abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en la entidad bancaria CAIXABANK, S.A., indicando en el concepto el número de referencia del procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento y la causa, por pago voluntario, de reducción del importe de la sanción. Asimismo, deberá enviar el justificante del ingreso a la Subdirección General de Inspección para proceder a cerrar el expediente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 76.4 de la LOPDGDD y dado que el importe de la sanción impuesta es superior a un millón de euros, será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción. En su virtud se le notifica cuanto antecede, y se le pone de manifiesto el procedimiento a fin de que en el plazo de DIEZ DÍAS pueda alegar cuanto considere en su defensa y presentar los documentos e informaciones que considere pertinentes, de acuerdo con el artículo 89.2 de la LPACAP.

C.C.C.
EL INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO

Índice del Expediente EXP202317662

(...)

>>

SEGUNDO: En fecha 22 de noviembre de 2024, la parte reclamada ha procedido al pago de la sanción en la cuantía de **1.600,00 euros** haciendo uso de la reducción prevista en la propuesta de resolución transcrita anteriormente.

TERCERO: La parte reclamada ha renunciado expresamente a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante LSSI) y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para resolver este procedimiento la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: *"Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se registrarán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos."*

Por último, la Disposición adicional cuarta "Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes" establece que: *"Lo dispuesto en el Título VIII y en sus normas de desarrollo será de aplicación a los procedimientos que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera de tramitar en ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes."*

II

Terminación del procedimiento

El artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), bajo la rúbrica *"Terminación en los procedimientos sancionadores"* dispone lo siguiente:

"1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente."

III Pago voluntario

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 85 de la LPACAP, en la propuesta de resolución notificada se le permitía llevar a cabo el pago voluntario de la sanción propuesta, lo que supondría la reducción de un **20% de su importe**. Con la aplicación de esta reducción, la sanción quedaría establecida en **1.600,00 euros** y su pago implicará la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la imposición de las medidas correspondientes.

Tras la citada propuesta de resolución, y antes de que se dictase resolución por parte de esta autoridad, la parte reclamada, en fecha 22 de noviembre de 2024, procedió a realizar el pago voluntario, acogiéndose a la reducción del 20% y renunciando a cualquier acción o recurso en vía administrativa.

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con los preceptos de la LPACAP, así como de la jurisprudencia del alto tribunal en esta materia, el ejercicio del pago voluntario por el presunto responsable no exime a la administración de la obligación de resolver y notificar todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. De igual forma, el artículo 88 de la citada norma establece que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de graduación de las sanciones cuya existencia ha quedado acreditada, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la comisión de las infracciones y CONFIRMAR las sanciones determinadas en la parte dispositiva de la propuesta de resolución transcrita en la presente resolución.

La suma de las citadas cuantías arroja una cantidad total de **2.000,00 euros**.

Tras haber procedido la parte reclamada al pronto pago, aunque sin reconocimiento de responsabilidad, se procede, en virtud del artículo 85 de la LPACAP, a la reducción de un 20% del total mencionado, lo cual supone la cantidad definitiva de **1.600,00 euros**.

SEGUNDO: DECLARAR la terminación del procedimiento **EXP202317662**, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la LPACAP.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a **MAXPOWER FITNESS NUTRITION, S.L.**

CUARTO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la LPACAP que condiciona la reducción por pago voluntario al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa, por parte de la presente autoridad se acepta la renuncia expresamente manifestada por la parte reclamada, no cabiendo en consecuencia la interposición de recurso potestativo de reposición frente a la presente resolución, todo

ello sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 90 de la LPACAP, dado que no cabe ningún recurso en vía administrativa al haber renunciado expresamente, la presente resolución será plenamente ejecutiva a partir de la notificación de la misma.

No obstante, conforme a lo previsto en el artículo 90.3 a) de la LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados, no siendo de aplicación lo estipulado en el 76.4 de la LOPDGDD como se indicaba en la propuesta de resolución.

968-15012025

Olga Pérez Sanjuán

La Subdirectora General de Inspección de Datos, de conformidad con el art. 48.2 LOPDGDD, por vacancia del cargo de Presidencia y Adjunta